VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE AÇAILÂNDIA

PROC. 0804285-49.2021.8.10.0022

Autor: YAGO RAVELLY BRANDAO PEREIRA (representado por ANTONIA BRANDÃO PEREIRA DE SANTANA)

Advogados: MARIA FRANCISCA CAZOTE PINHO (OAB/MA 15.039) e LUIZ NILDO ALENCAR DE LIMA (OAB/BA 14.556)

Réus: MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA e ESTADO DO MARANHÃO

Classe processual: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

SENTENÇA

1. RELATÓRIO

Trata-se de ação formalizada pelo procedimento comum, com pedido de tutela provisória de urgência, por YAGO RAVELLY BRANDAO PEREIRA – representado por sua genitora ANTONIA BRANDÃO PEREIRA DE SANTANA – em face do MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA e do ESTADO DO MARANHÃO.

A presente demanda tem o escopo de compelir os referidos entes públicos a garantir ao autor – portador de microcefalia (CID 10 Q02) – a realização de cirurgia de colecistectomia por videolaparoscopia e demais procedimentos médicos necessários a seu tratamento de saúde.

Consta da exordial que a genitora do demandante buscou ajuda na Secretaria de Saúde do Município de Açailândia, a fim de que fosse agendada a aludida cirurgia, todavia não tivera resposta. Em nova oportunidade, solicitou a abertura de processo de T.F.D., o que, porém, fora-lhe negado.

Dessa forma, não tendo o autor condições financeiras de custear as despesas médicas com seu tratamento, é que recorre ao Poder Judiciário, requerendo tutela provisória de urgência, a fim de que se imponha aos réus o dever de realizar o procedimento cirúrgico de colecistectomia por videolaparoscopia e outros necessários e indicados pelo médico especialista.

No mérito, requesta a confirmação da medida antecipada, além de pleitear os benefícios da justiça gratuita.

Com a inicial vieram anexados documentos.

Por meio do despacho de ID nº 51678277, ordenou-se a notificação dos réus para se manifestarem, em 72h, acerca do pedido antecipado, prestarem a informação sobre a existência de fila de regulação de leitos, determinado-se, ainda, a emissão de parecer técnico pelo NatJus Nacional.

Nota Técnica favorável (ID nº 51721915).

Deferida a tutela de urgência vindicada, em decisão de ID nº 51742707, oportunidade também em que concedida a benesse da gratuidade judicial.

Em petição de ID nº 51788486, o ente municipal pede a reconsideração do *decisum*.

O Estado do Maranhão, por sua vez, noticia que a cirurgia em apreço foi agendada para 14/09/2021 (ID nº 51943207).

O postulante, informando a impossibilidade de aguardar até a data agendada para realização do procedimento cirúrgico, pleiteia o bloqueio de verbas públicas (ID nº 52030861).

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Maranhão opina pelo deferimento do bloqueio de verbas (ID nº 54067019).

Em nova manifestação, o ente municipal relata a realização da medida urgente deferida (ID nº 54101531).

Na peça contestatória (ID nº 54825746), por outro lado, o Estado do Maranhão argumenta preliminarmente sua ilegitimidade passiva, na espécie.

No mérito, sustentando não ter condições financeiras de custear as despesas oriundas do tratamento do paciente em questão sem comprometer o atendimento aos demais e que a saúde não se constitui em um direito subjetivo individual, mas coletivo, pede que seja julgado improcedente o pleito autoral.

O Município de Açailândia, por seu turno, na contestação de ID nº 54991069, alega: a) sua ilegitimidade passiva; b) que a saúde é um direito social de segunda dimensão, pelo que, para sua satisfação, deve ser observada a reserva do possível; c) que eventual condenação do município tem que se ater às consequências práticas da decisão e; d) a impossibilidade de aplicação de *astreintes* contra a Fazenda Pública.

Em mais uma oportunidade, o demandante pontua "*que o ente público comprovou nos autos A REALIZAÇÃO APENAS DA CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA, estando o autor aguardando a realização da COLANGIOPANCREATOGRAFIA (CPRE), necessária para intervenção da coledocolitíase, complicação mais gravosa*". Assim, requesta que seja providenciada avaliação pelo médico especialista a fim de realizar a intervenção cirúrgica de Colangiopancreatografia (CPRE), a expensas dos requeridos, em hospital privado, onde o serviço especializado esteja disponível. Pede, por fim, prazo para juntada de orçamentos do valor do procedimento.

Em parecer de mérito, o *Parquet "manifesta-se pelo julgamento antecipado da lide com o julgamento procedente para condenar o MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA e o ESTADO DO MARANHÃO a fornecer o tratamento médico necessário para o quadro de saúde do paciente*" (ID nº 59974148).

É o que cabia relatar.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, registro a desnecessidade de realização de audiência de instrução e julgamento, ante a suficiente documentação do acervo probatório já coligido aos autos para formação de convicção acerca da lide.
Assim, passo ao julgamento do processo no estado em que se encontra, na forma do art. 355, inciso I, do CPC.

Com efeito, a vertente demanda fora proposta por Yago Ravelly Brandão Pereira – representado por sua genitora Antonia Brandão Pereira de Santana – com o objetivo de compelir o Município de Açailândia e o Estado do Maranhão a garantirem a realização de cirurgia de colecistectomia por videolaparoscopia e demais procedimentos médicos necessários a seu tratamento de saúde.

Cumpre, a princípio, examinar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelos réus, que desde já adianto não prosperar.

Isso porque, no RE 855.178 (tema 793 da Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal, à luz dos artigos 2º e 198 da Constituição Federal, concluiu pela responsabilidade solidária entre os entes federados no que tange à promoção dos atos necessários à concretização do direito à saúde. Vejamos:

> "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". (RE 855.178 - Tema 793 da Repercussão Geral).

Destarte, rejeito o argumento de ilegitimidade passiva, suscitado por ambos os demandados.

No mérito, cumpre destacar que o direito à saúde – suscitado nos autos – encontra amparo nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, *in verbis*:

> "CF/88, Art. 6º - São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição".

> "CF/88, Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

Ademais, nos termos do artigo 5º, §1º, da Carta Política brasileira, "*As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata*".

Daí porque a jurisprudência entende que, em casos específicos, o Estado pode ser demandado concretamente para fazer prevalecer o direito à saúde.

Acerca do tema, colaciono os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente:

> "DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) – PRECEDENTES (STF) – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO". (ARE 1058131 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 11/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018). Grifou-se.

> "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. 1. No que tange à responsabilidade em prover o tratamento da saúde da pessoa humana, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico, conforme premissa contida no art. 196 da Constituição Federal. 2. Ainda, considerando que o Sistema Único de Saúde é financiado pela União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 198, § 1º, da Constituição Federal, pode-se afirmar que é solidária a responsabilidade dos referidos entes na prestação dos serviços públicos de saúde à população. 3. O direito constitucional à saúde faculta ao cidadão obter de qualquer dos Estados da federação (ou do Distrito Federal) os medicamentos de que necessite, dispensando-se o chamamento ao processo dos demais entes públicos não demandados. Desse modo, fica claro o entendimento de que a responsabilidade em matéria de saúde é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federados (...)" (AgInt no AREsp 1635297/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 22/10/2020). Grifou-se.

Além disso, em virtude do caráter fundamental, o direito à saúde sobrepõe-se a quaisquer atos normativos infralegais ou mesmo à legislação infraconstitucional, cabendo ao Judiciário fazer valer, no caso concreto, as determinações constitucionais que atribuem ao Estado o dever de prover a saúde de seus cidadãos.

Acerca do tema, segue elucidativo precedente do STF:

> "RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO MÉDICO. DEVER DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. De início, pontuo que, consoante já afirmado na decisão recorrida, o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto ou isoladamente. 2. Ademais, esta Corte já firmou entendimento no sentido de que o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não implica violação ao princípio da separação dos Poderes (CF, artigo 2º), porquanto não se trata, nessas hipóteses, de análise das circunstâncias que circunscrevem ao mérito administrativo. 3. Por fim, cumpre ressaltar que também não assiste razão ao agravante ao sustentar que o Estado não está obrigado a fornecer medicamento não constante na lista da SUS, conforme muito bem assinalado pelo Ministro Joaquim Barbosa na decisão proferida no AI 821.769, DJe de 9/11/2010. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (Ag. Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo nº 831.915/RO, 1ª Turma do STF, Rel. Roberto Barroso. j. 05.04.2016, unânime, DJe 04.05.2016).

Dessa forma, incumbe ao Poder Judiciário analisar atos praticados pelo Administrador Público, para que, em havendo recusa do dever de prestar os serviços essenciais de saúde por parte da Administração, haja também a judicialização da celeuma, de modo a possibilitar que o Estado seja compelido a guardar estrita observância aos direitos constitucionais à saúde, à vida e à dignidade humana dos administrados.

Em casos análogos, não é outro o entendimento da Corte Suprema, *in verbis*:

> "DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 279/STF. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. 2. O acórdão recorrido também está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. 3. A controvérsia relativa à hipossuficiência da parte ora agravada demandaria a reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é viável em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento". (Ag. Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo nº 894085/SP, 1ª Turma do STF, Rel. Roberto Barroso. j. 15.12.2015, unânime, DJe 17.02.2016). Grifou-se.

No que tange às alegações de que as normas que regulamentam a saúde são de caráter programático e de ausência de recursos para atender a todas as demandas, impende consignar que isso não quer significar que o Estado/Município deve se omitir em garantir a saúde por meio de políticas sociais e econômicas. Na verdade, impõe-se aos entes políticos a realização de planejamento para a implementação de tal direito.

Assim sendo, se o Município/Estado se exime do dever de assegurar o direito a saúde, surge a possibilidade de o Judiciário concretizá-lo.

Não se está aqui violando a separação dos poderes, mas tão somente observando o princípio da legalidade, a fim de que o Município de Açailândia e o Estado do Maranhão cumpram com o dever de zelar pela saúde da população.

Da mesma forma, inadmissível falar em impossibilidade financeira. A mera alegação de falta de recursos não é bastante para afastar o dever de providenciar os cuidados à saúde do cidadão. A simples inexistência de dotação orçamentária específica não obsta a cominação da obrigação contra o ente público, salvo se comprovadamente não houver recursos disponíveis. Nesse sentido, é elucidativa a lição que ora transcrevo:

> "Tratando-se de impossibilidade jurídica, o que decorreria não da ausência de receita, mas da ausência de previsão orçamentária para a realização da despesa, deverá prevalecer o entendimento que prestigie a observância do mínimo existencial. Restando incontroverso o descompasso entre a lei orçamentária e os valores que integram a dignidade da pessoa humana, entendemos deva esta prevalecer, com o consequente afastamento do princípio da legalidade da despesa pública. Não fosse assim, seria tarefa assaz difícil compelir o Poder Público a observar os mais comezinhos direitos assegurados na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, o que tornaria por tornar legítimo aquilo que, na essência, não o é. Não é demais lembrar que, ao consagrar direitos, o texto constitucional implicitamente impôs o dever de que sejam alocados recursos necessários à sua efetivação. Em se tratando de direito coletivos que normalmente exigem um elevado montante de recursos, apelar para a expedição de precatórios, consoante a sistemática do art. 100 da Constituição, seria o mesmo que relegar os verdadeiros detentores da facultas agendi às intempéries da própria sorte, arcando com os efeitos deletérios e irreversíveis que o fluir do tempo causaria sobre seus direitos. Como desdobramento do que vem de ser dito, poderá o Poder Judiciário, a partir de critérios de razoabilidade e com a realização de uma ponderação responsável dos interesses envolvidos, determinar a realização dos gastos na forma preconizada, ainda que ausente a previsão orçamentária específica.Caberá ao Poder Executivo, nos limites de sua discrição política, o contingenciamento ou o remanejamento de verbas visando a tornar efetivos os direitos que ainda não o são." (GARCIA apud OLSEN, Ana Carolina Lopes. Direitos fundamentais sociais: efetividade frete à reserva do possível. 1. ed. Curitiba: Juruá Editora. p. 330.)" Grifou-se.

Destaque-se ainda a ressonância dessa tese na jurisprudência, sabiamente reconhecendo a não oponibilidade da reserva do possível ao mínimo existencial:

> "REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA - DIREITO À SAÚDE - ART. 196 DA CR/88 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - MÍNIMO EXISTENCIAL E CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL - NECESSIDADE COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA. - Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, deve o Poder Público garantir imediatamente um 'mínimo existencial' no que se refere às normas constitucionais programáticas com reflexo nos direitos fundamentais. - Assim, o direito à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição da República, é dever do Estado, o que o obriga ao fornecimento de tratamento médico adequado e dos medicamentos disponíveis, m reexame necessário. - Recurso voluntário prejudicado". (TJMG - Número do 1.0109.13.001381-5/001 Numeração 0013815- Relator: Des.(a) Lobservada a cláusula da reserva do possível. - Confirmada a sentença euís Carlos Gambogi Relator do Acordão: Des. (a) Luís Carlos Gambogi - Data do Julgamento: 25/05/2017 - Data da Publicação: 13/06/2017). Grifou-se.

In casu, não foi colacionado aos autos qualquer documento comprobatório da incapacidade econômico-financeira dos réus, razão pela qual não merece guarida a alegação de incapacidade econômica.

É crescente o número de demandas judiciais visando à consecução de medidas assecuratórias dos direitos fundamentais à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana.

Depreende-se daí a frequente omissão do Estado-Administração no cumprimento da sua incumbência constitucional de zelar pelo bem-estar social, promovendo em prol dos administrados políticas públicas permanentes e eficazes, voltadas à prevenção e tratamento de doenças de todas as complexidades.

Em olvidando esta premissa àqueles que deveriam precipuamente observá-la, fazem-se necessários provimentos jurisdicionais com o escopo de modificar a realidade fática, dando cumprimento aos mandamentos maiores da Constituição.

No caso vertente, a inicial apresenta elementos probatórios da necessidade de que o autor receba o atendimento necessário para a recuperação/manutenção da sua saúde.

Nesse sentido, a parte autora juntou ao processo os laudos que atestam sua debilitada situação de saúde, bem como a necessidade de procedimentos cirúrgicos que visem amenizar os males de sua condição, que constituem fundamento para o atendimento da demanda pelo Poder Público.

Ademais, a Lei nº 8.080/1990, traz como caráter fundamental o direito à saúde, além de fixar a garantia do bem-estar físico, mental e social das pessoas, por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, *in litteris*:

> Art. 2º. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
>
> § 1.º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação […].

Destarte, o reconhecimento dos direitos à vida e à saúde, consagrados constitucionalmente, basta para a solução do labor hermenêutico empreendido no seio desta lide.

Além disso, ressalta-se o princípio da máxima efetividade, através do qual se deve preferir o sentido que atribua maior eficácia à norma constitucional como a projeção nítida de um direito fundamental ligado à sobrevivência digna aqui tratada.

Desse modo, qualquer norma constitucional, mas principalmente as que veiculam direitos fundamentais, submetem-se ao princípio da máxima efetividade.

Por derradeiro, quanto à tese de impossibilidade de aplicação de *astreintes* em desfavor da Fazenda Pública, sabe-se que a jurisprudência do STJ está pacificada em sentido oposto, por constituir meio de coerção cuja finalidade é compelir o Estado ao cumprimento de uma determinação judicial, de sorte que somente será necessária a medida em caso de descumprimento do comando judicial, não havendo, por isso, razão para que seja afastada.

Sobre a matéria, confiram-se:

> "(...) A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.474.665/RS, afetado ao rito do art. 543-C do CPC/1973, estabeleceu a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública na hipótese de descumprimento da obrigação de fornecer medicamento. Na mesma linha: AREsp 1.579.684/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/5/2020. (STJ, AgInt no AREsp 1777312/PE, Relator Ministro Herman Benjamin, Órgão Julgador: Segunda Turma, Data do Julgamento 16/08/2021, Data da Publicação DJe 31/08/2021).

> "(...) A jurisprudência do STJ está pacificada, no sentido de que é perfeitamente possível a imposição de multa à Fazenda Pública, nos termos dos arts. 461 c/c art. 461-A do CPC , pois constitui meio de coerção e tem por objetivo compelir o Estado ao cumprimento de uma determinação judicial. O pagamento de multa somente será devido em caso de descumprimento da decisão judicial, não havendo, por isso, razão para que seja afastada, ou mesmo reduzida, sob pena de que, ao ser fixada em valor irrisório, não alcance o efeito coercitivo almejado (...)"(Remessa Necessária 18623/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/08/2015, Publicado no DJE 12/08/2015).

Portanto, de rigor, a procedência do pleito autoral.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a presente ação, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para, confirmando a tutela antecipada, condenar o Município de Açailândia e o Estado do Maranhão a providenciarem para YAGO RAVELLY BRANDAO PEREIRA a realização da cirurgia de colecistectomia por videolaparoscopia e demais procedimentos médicos e cirúrgicos necessários a seu tratamento de saúde.

Condeno os réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inexistindo interposição de recurso voluntário, no prazo legal, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado Maranhão com vistas ao cumprimento do disposto no art. 496, inciso I, do CPC[1].

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se.

Açailândia, assinado e datado eletronicamente.

José Pereira Lima Filho

[1] CPC, Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

Assinado eletronicamente por: JOSE PEREIRA LIMA FILHO
23/03/2022 09:49:03
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 63274513

22032309490335600000059221745

IMPRIMIR GERAR PDF